

1500317-36.2021.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... se Victor Hugo respondia a processo por tráfico. Não localizaram anotações ou petrechos referentes ao tráfico no imóvel. Afirma que a droga seria destinada ao tráfico pela quantidade.

Como se nota, a versão apresentada pelo réu Victor Hugo é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de drogas, constata-se, na realidade, que as substâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500317-36.2021.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-36.2021.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2336688/2021 - 1º Distrito Policial de Jales, 4521/2021 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE MELLO LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

VICTOR HUGO DE MELLO LIMA (filho de Rodrigo Tarin de Lima e Lizania Seguro de Melo, nascido em 08/01/1999, natural de Jales/SP, RG 52195174) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j" (pandemia), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, na Rua Gilorde Eumene Garzella, nº 72, JACB, nesta cidade e Comarca de Jales-SP, nas imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de

terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida vulgarmente como "maconha", com peso líquido aproximado de 29,37 gramas; 01 (uma) porção de COCAÍNA, com peso líquido aproximado de 9,78 gramas, acondicionada em invólucro plástico; e 150 (cento e cinquenta) comprimidos de METANFETAMINA, popularmente conhecido como "ecstasy", com peso líquido aproximado de 60,57 gramas, prontos para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (p. 171), o réu defendeu-se previamente por intermédio de advogado constituído (p. 175/177).

Recebeu-se a denúncia em 08 de março de 2022. Na ocasião, revisou-se a necessidade da prisão preventiva, que se manteve (p. 178/182).

O réu foi citado pessoalmente (p. 213).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas (Eduardo Pereira Missias e Igor Alexandre Murari Cardozo). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo-se em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Suscitou a incidência da circunstância agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, bem como da causa de aumento de pena descrita do art. 40, inciso III, da LD. Refutou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como requereu o cumprimento inicial da pena em regime fechado. Por fim, postulou a decretação do perdimento da quantia apreendida (p. 221/239).

A defesa, em alegações orais, pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Pugnou pela desclassificação do delito para o previsto do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD. Refutou a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP e da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD (p. 271/283).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) está provada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 22/24), pelos autos de exibição e apreensão (p. 28/29 e 134), pelo laudo de constatação prévia (p. 88/92), pelos laudos de exame definitivo de entorpecente (p. 131/133 e 136/138) - que atestaram que as drogas apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida vulgarmente como "maconha", cocaína e metanfetamina -, bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Victor Hugo, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de drogas. Admitiu a propriedade dos entorpecentes. É usuário de drogas. Comprou a droga com o décimo terceiro que ganhou de presente da mãe. Trabalhava como mototaxista nos três períodos do dia. Comprou o entorpecente, no dia sete de dezembro de 2021, em Jales-SP. Usava cocaína diariamente, porque descobriu que não era o pai do filho da companheira. Consumiria o "ecstasy" em festas. Pagou mil e quinhentos reais pelos comprimidos de "ecstasy", cinquenta reais pela "maconha" e duzentos e cinquenta reais pela cocaína. Não entregava drogas pela cidade. Usava de vinte a trinta comprimidos de "ecstasy" por festa. A droga seria consumida em festas. Foi condenado por este juízo em outro processo de tráfico, no qual foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Respondeu por ato infracional análogo ao tráfico de drogas também.

Eduardo Pereira Missias, investigador de polícia, apoiou o cumprimento de mandado de busca domiciliar na residência do réu, cujo objetivo maior seria encontrar arma de fogo. Havia informações de que o réu praticava tráfico de drogas, mas sem investigações concretas em andamento. Localizaram os comprimidos de "ecstasy" em cima do cesto de roupa suja, a porção de "maconha" na cozinha e a "cocaína" dentro de uma blusa pendurada no varal. Indagado, Victor Hugo afirmou que o entorpecente era para consumo próprio. Não sabe se o réu já foi processado por tráfico, mas

havia informações de que ele traficava. Pela quantidade de drogas apreendidas, não acredita que o entorpecente era para consumo do réu. Não localizaram petrechos no imóvel. Um comprimido de "ecstasy" custa de cinquenta a noventa reais. Sabe que o réu fazia entregas em uma pizzaria.

Igor Alexandre Murari Cardozo, investigador de polícia, colaborou no cumprimento de mandado de busca e apreensão originária da "DDM", em que a esposa de Victor Hugo noticiou a existência de arma de fogo no imóvel. Receberam informações de que o réu realizara "delivery" de drogas sintéticas em festas "rave". Durante a diligência, localizaram uma porção de "maconha" na cozinha, a porção de cocaína em uma blusa no varal e os comprimidos de "ecstasy" no banheiro. Encontraram quantia em dinheiro no imóvel. Não localizaram a arma de fogo. O réu disse que o entorpecente era para consumo próprio. Não sabe se Victor Hugo respondia a processo por tráfico. Não localizaram anotações ou petrechos referentes ao tráfico no imóvel. Afirma que a droga seria destinada ao tráfico pela quantidade.

Como se nota, a versão apresentada pelo réu Victor Hugo é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de drogas, constata-se, na realidade, que as substâncias apreendidas destinavam-se à aquisição por terceiros.

Mormente levando-se em consideração a quantidade e variedade (uma porção de "maconha", uma porção de cocaína e cento e cinquenta comprimidos de "ecstasy") de drogas que o réu armazenava na residência. Além do mais, houve a localização de montante em dinheiro (R\$280,00), fracionado em diversas notas menores - circunstâncias incomuns aos meros usuários.

De acordo com os relatos de Eduardo e Igor, em que pese a busca domiciliar ter sido autorizada para localização de arma de fogo, havia informações na "DISE" de Jales-SP sobre o envolvimento de Victor Hugo no tráfico de drogas.

Inclusive o investigador Igor declarou que o réu seria o responsável por realizar "delivery" de drogas sintéticas em festas "rave".

Chama atenção o elevando valor (R\$7.500,00 a R\$13.500) dos entorpecentes armazenados pelo réu em sua residência, haja vista que, conforme declarou o investigador Eduardo, cada comprimido de "ecstasy" custaria entre cinquenta e noventa reais. Tal circunstância deixa nítido que Victor Hugo investiu em entorpecentes no intuito de obter lucro com a mercancia a terceiros.

Logo, é evidente o crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo réu.

Percebe-se, portanto, que a tese de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo suscitada pela defesa não merece amparo. O fato ser usuário de droga não exclui a possibilidade de, também, se dedicar à comercialização do entorpecente. Como se sabe, muitos dependentes passam a traficar como forma de sustentar o próprio vício. Além do mais, o réu apresentou-se calmo, com fala articulada e raciocínio coerente, não demonstrando indícios de que seja usuário severo de drogas.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Victor Hugo, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecida vulgarmente como "maconha", com peso líquido aproximado de 29,37 gramas; 01 (uma) porção de COCAÍNA, com peso líquido aproximado de 9,78 gramas, acondicionada em invólucro plástico; e 150 (cento e cinquenta) comprimidos de METANFETAMINA, popularmente conhecido como "ecstasy", com peso líquido aproximado de 60,57 gramas, prontos para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Afasto a causa especial de aumento de pena descrita no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06. Segundo o laudo de p. 165/169, o imóvel em que o réu armazenava entorpecentes localiza-se nas imediações de uma escola (Escola Municipal de Educação Infantil Deva Maciel Jorge).

O Superior Tribunal possui o entendimento de que "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais

estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância." (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

Desse modo, para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, basta que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações das localidades relacionadas no dispositivo legal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei. Contudo, mesmo que se reconheça a natureza objetiva da aplicação da causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não seria razoável reconhecê-la na espécie. É que o imóvel do réu – local utilizado como ponto de referência para aferir a existência do estabelecimento listado no laudo pericial – destinava-se apenas ao armazenamento do entorpecente. Como relatado pelo investigador Igor, o réu entregava os entorpecentes em sistema de “delivery” para usuários frequentadores de festa “rave” na região. Portanto, não há provas do desempenho da mercancia nas proximidades dos locais listados no mencionado inciso, apenas o mero depósito da droga no imóvel situado perto de um deles. Pensar o contrário seria responsabilizar objetivamente o réu pelo simples fato de morar em determinado local, o que é vedado no âmbito criminal.

Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu, tecnicamente, não ostenta maus antecedentes criminais. Nota-se pela certidão de objeto e pé de p. 200/201 que possui condenação criminal por tráfico de drogas (Processo nº 1500728-51.2020.8.26.0297, desta 2ª Vara Criminal de Jales-SP), porém sem notícia de trânsito em julgado. Por outro lado, deve ser sopesada a grande quantidade (uma porção de cocaína, uma porção de maconha e cento e cinquenta comprimidos de “ecstasy”) de droga apreendida, denotando maior censurabilidade ao comportamento do réu. Desse modo, inauguro a pena base acima do mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e nem atenuantes a serem sopesadas. Não há de se falar na incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o réu contava com mais de vinte um anos de idade (nascido em 08/01/1999, p. 200) na data dos fatos (10/12/2021). Frise-se que a circunstância agravante descrita no art. 61, II, “j”, do CP, deve ser afastada, porque não ficou demonstrado que o réu se prevaleceu da pandemia para praticar o crime. Por isso, mantém-se a pena provisória no mesmo patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Consigne-se que este juízo vinha levando em consideração a reiteração na prática do tráfico de entorpecentes – ainda que em processamento – para afastar o privilégio legal. Todavia, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento da Quinta e Sexta Turmas – para alinhá-las às decisões do Supremo Tribunal Federal –, no sentido de que “(...) a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal” (HC 664.284/ES, Quinta Turma do STJ, rel. Ministro Riberio Dantas, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021), E, também, “(...) A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado” (RHC 210056 AgR, da Segunda Turma do STF, rel.

Ricardo Lewandowski, julgado em 09/03/2022). Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena de multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e o réu é primário. Consigne-se que a equiparação à hediondez do tráfico privilegiado foi afastada por decisões do Superior Tribunal Federal (HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese Firmada no Tema 600 dos Recursos Repetitivos, publicada em 29/11/2016). Portanto, não deve incidir a determinação do § 1º do artigo de 2º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de computar o período de prisão provisória para fins de detração determinado pelo §2º do art. 387 do CPP, ante a fixação o regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), a ré não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 5 (cinco) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno VICTOR HUGO DE MELLO LIMA (filho de Rodrigo Tarin de Lima e Lizania Seguro de Melo, nascido em 08/01/1999, natural de Jales/SP, RG 52195174) como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça gratuita.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois o tipo de pena aplicada incompatibiliza-se com a prisão preventiva. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Com relação à quantia (R\$280,00) - constante do auto de apreensão e exibição de p. 28/29 -, considerando que o condenado não comprovou a origem lícita do valor, bem como por guardar correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao celular "Samsung" apreendido em posse do réu (auto de exibição e apreensão p. 134), não havendo provas de que tenha sido utilizado para prática do

crime em análise, autorizo a restituição. Intime-se o réu para retirá-lo no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, será o bem considerado coisa abandonada ("res derelicta"), com destinação do aparelho à doação.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeça-se guia de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação da quantia declarada perdida em favor da União, indicando o local em que se encontra e o órgão em cujo poder esteja, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA